

1502743-97.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, em junho de 2021, autos 1501344-33.2021, cujo processo ainda está em tramitação. A proximidade das duas prisões em flagrante, ocorridas no mesmo semestre, sugere que ele teria mais do que um envolvimento pontual com o tráfico, que se dedica com alguma regularidade a essa atividade, o que é incompatível com o benefício do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502743-97.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502743-97.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RAFAEL VITORIANO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DANIEL DA SILVA MACOLINO e RAFAEL VITORIANO DA SILVA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 12h, na Rua União, número 1, Jardim Santa Mônica nesta cidade e comarca, em concurso de agentes com o inimputável Thiago Eduardo Sousa Ferreira dos Santos, traziam consigo 17 porções de maconha e 15 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 6/7), assim como o laudo de constatação (fls. 33/35) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 128/130). Foi concedida liberdade provisória ao réu Rafael (fls. 115/117). Ele foi posto em liberdade em 14 de dezembro de 2021 (fls. 124/127).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 133 e 142) e apresentaram defesa preliminar (fls. 150/151). Em 11 de maio de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fl. 154). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us) (fls. 161/162 e 168/169). As partes apresentaram alegações finais ainda em audiência (fls. 168/169).

É o relatório. Decido.

Os(As) rés(us) DANIEL DA SILVA MACOLINO e RAFAEL VITORIANO DA SILVA foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque em 25 de novembro de 2021, por volta das 12h, na Rua União, número 1, Jardim Santa Mônica nesta cidade e comarca, em concurso de agentes com o inimputável Thiago Eduardo Sousa Ferreira dos Santos, traziam consigo 17 porções de maconha e 15

porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis receberam informação anônima sobre o tráfico de drogas no local, observaram a presença dos dois réus, que se revezavam para realizar a venda do entorpecente, e do adolescente, que atuava como "olheiro". Realizada a abordagem, foi encontrada uma sacola com as drogas acima discriminadas, além de R\$80,00 com o réu Rafael e R\$60,00 com o réu Daniel.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade de drogas não é indicativa, por si só, de tráfico. Mas o fato de haver dois tipos de drogas distintos e as circunstâncias em que foram encontradas não deixam dúvida de que o era.

A questão é se os réus realmente foram os autores desse crime, pois o réu Daniel, no interrogatório judicial, negou que estivesse com drogas. Ele ressaltou que havia 10 dias que estava em liberdade e tinha ido ao uma doceria. Pediu licença a um policial, sem saber que o era, ocasião em que ele começou a perguntar se ele já tinha passagem e resolveu abordá-lo. Notou que mais dois rapazes tinham sido abordados fora da doceria. De repente, os policiais disseram que encontraram drogas e o prenderam.

O réu Rafael seguiu, basicamente, a mesma linha exposta acima. Ele disse que tinha ido ao local comprar maconha. Tinha consigo R\$ 10,00. Os policiais chegaram e o abordaram. O traficante saiu correndo. Notou que Daniel e um adolescente estavam em local próximo e também foram abordados, mas não os conhecia. Daniel estava com uma garrafa de refrigerante.

Essas são negativas verossímeis. É claro que os réus poderiam estar no local apenas para comprar doces ou drogas, respectivamente. Elas não merecem prosperar, contudo, pois além de não serem harmônicas entre si, são frágeis, ainda mais se comparadas com as peças informativas e provas que sustentam a acusação, como permite o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Na fase policial e em juízo as testemunhas Cláudio e Rogério declararam que são policiais civis e na data do fato foram ao local averiguar informação anônima sobre a presença de traficantes. Identificaram os dois réus, que se revezavam para interagir com os usuários, recebendo dinheiro e entregando drogas a eles. Um adolescente parecia estar de vigia, como "olheiro". Realizada a abordagem, sob a posse dos dois réus encontraram dinheiro. Também apreenderam uma sacola contendo drogas. Ela estava com o réu Daniel Na ocasião, os réus admitiram que se revezavam para vender as drogas.

Consoante jurisprudência pacífica, o depoimento dos policiais não pode ser desacreditado apenas porque de policiais, isto é, de agentes que, em tese, tenderiam a defender em juízo a regularidade de suas ações. Na verdade, a credibilidade do depoimento deles deve ser analisada em consonância com as demais provas produzidas. É do cotejo entre elas que se pode dizer que uma prova qualquer é mais ou menos crível.

Na espécie, não há um indicativo sequer de que os policiais agiram indevidamente, de que queriam prejudicar os réus, de que deixaram fugir traficantes e prenderam os réus apenas por uma questão pessoal. Em suma, o depoimento que eles prestaram é crível, o que, somado à prova da materialidade das drogas e à fragilidade da prova das alegações defensivas, permite que os réus sejam condenados.

Quanto à menção na denúncia a respeito do envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, importa observar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 somente pode ser aceita se alguns requisitos forem preenchidos.

"Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil -como o número do

documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.” (tema 1052 do STJ)

No caso, o adolescente foi corretamente qualificado e segundo consta exibiu o RG original na delegacia (fl. 4).

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena verifico que o crime praticado pelos réus teve como objeto 17 porções de maconha e 15 de cocaína. A quantidade não é muito expressiva, mas como se trata de dupla variedade, deve ser aplicada a regra do artigo 42 da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ – 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Em razão do exposto, fixo a pena-base para o réu Rafael em 5 anos e 6 meses de reclusão.

O réu Daniel também tem Maus antecedentes, pois foi condenado definitivamente em 13/06/2016, nos autos 0034927 44 2014 (fls. 73/74), que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal de Sorocaba, então fixo a pena-base para ele em 6 anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena para o réu Rafael está presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data do fato, então torno a pena ao patamar mínimo. Não há agravantes.

Para o réu Daniel, ao contrário, está presente a agravante da reincidência, pois foi condenado nos autos 0004291 97 2015, da 1ª Vara de Jandira e o trânsito em julgado operou-se em 23/08/2018 (fl. 73). Em razão disso, por analogia ao artigo 110 do Código Penal, exaspero a pena em 1/3, perfazendo 8 anos de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, está presente a causa de aumento do artigo 40, VI, de 1/6 a 2/3. Como o adolescente envolvido no ilícito tinha apenas 14 anos de idade, e presumivelmente quanto mais jovem tanto mais influenciável, o que torna mais repreensível a conduta dos imputáveis, elevo a pena em metade, perfazendo 7 anos e 6 meses para o réu Rafael e 12 anos de reclusão para o réu Daniel.

Para o réu Daniel não há causa de diminuição de pena na terceira fase de aplicação da pena. Por efeito da reincidência e Maus antecedentes, ele não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33. Torno definitiva a cominação de 12 anos de reclusão. Quanto ao réu Rafael, embora seja primário, ele foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, em junho de 2021, autos 1501344-33.2021, cujo processo ainda está em tramitação. A proximidade das duas prisões em flagrante, ocorridas no mesmo semestre, sugere que ele teria mais do que um envolvimento pontual com o tráfico, que se dedica com alguma regularidade a essa atividade, o que é incompatível com o benefício do §4º do artigo 33. No entanto, como é posicionamento pacífico da jurisprudência do STJ que processos em andamento não podem ser utilizados para esse fim (Tema 1.139), aplico a causa de diminuição em tela.

Mercê do envolvimento de três pessoas para a consecução dos fins ilícitos, entendo ser o caso de reduzir a pena do réu Rafael pela metade, de tal modo que ela fica consolidada em 3 anos e 8 meses de reclusão.

Uma vez que o réu Daniel é reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. O réu Rafael, entretanto, sendo primário, não tendo maus antecedentes e tendo a pena sido fixada em patamar inferior a 4 anos, poderá iniciar o cumprimento dela no regime aberto.

Nesta linha, como estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do réu Rafael por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada: para o réu Daniel 1200 dias-multa; para o réu Rafael 375 dias-multa em dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) rés(us) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar como incurso no artigo 33, caput, os réus:

DANIEL DA SILVA MACOLINO ao cumprimento de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo

RAFAEL VITORIANO DA SILVA, ao cumprimento de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Considerando a reincidência e maus antecedentes do réu Daniel, é de se supor que sua liberdade representa risco à ordem pública, por isso não é adequado que possa recorrer em liberdade. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontram.

Ao réu Rafael foi concedida a liberdade no curso do processo e não sobreveio fato novo denotativo de que ele não possa conservá-la até o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) rés(us) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA